

CAPÍTULO II

LAS SOCIEDADES

1. EL ORIGEN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Las sociedades comerciales, con ciertas características similares a las actuales, tienen su origen y punto de partida en la Edad Media. En particular los tipos que hoy reconocemos como sociedad colectiva y en comandita. La sociedad anónima aparece en la Edad Moderna; pues como lo afirma Ripert, es un maravilloso instrumento creado por el capitalismo moderno.

Su modo de evolución ha sido diverso, pues originariamente se trataba de meras agrupaciones a través de las cuales los socios o integrantes de la comunidad societaria, que se reunían para llevar adelante un emprendimiento común, actuando cada uno de ellos, aquél al que se indicara debía actuar, en nombre de todos ellos, generando la insipiencia de lo que posteriormente se conocería como la sociedad en nombre colectivo o colectiva. El origen de estos instrumentos mercantiles se ubica en las ciudades italianas de la Edad Media, como derivación del vínculo familiar.

Vivante recuerda que las primeras sociedades de este tipo fueron conformadas por hermanos, y que se relacionaron con la dificultad física que implicaba construir en ciudades amuralladas, la falta de espacio y capital, junto con la dificultad que presentaba la división del patrimonio hereditario indiviso, lo que llevaban a que se continuara la actividad paterna bajo el mismo techo y con la misma organización.

Posteriormente se fue perfeccionando el sistema y se intentó limitar -en cierto modo- la responsabilidad, generándose algún tipo de sociedad de responsabilidad ilimitada y, como indica Malagarriga, desde esa primera matriz, el tipo acompañó la actividad de la pequeña industria doméstica, organizada fundamentalmente en pequeños talleres, y las sociedades comenzarán a ser integradas no sólo por miembros de la familia, lo que supuso la *generalización del tipo social*.

Respecto de las denominadas *sociedades en comandita*, algunos autores encuentran su origen en el derecho romano, por medio de la *institoria romana*, resultado del disfavor con que se reputaba el ejercicio del comercio; otros en cambio, creen que estuvo emparentada al préstamo marítimo a la gruesa -*foenus nauticum*-. Sin embargo, una importante cantidad de autores consideran que el origen del tipo está en la Edad Media, como derivado del contrato de *comanda* o *encomienda*, a través del cual una persona confiaba a un mercader o a un marino un capital para que lo hiciera producir, tomando una parte de los beneficios. Resulta interesante destacar que el tipo cobró importancia por el uso que le dieron, por un lado, los nobles, que en razón de su clase no podían ejercer abiertamente el comercio, y la iglesia, al prohibir el préstamo a interés -Malagarriga y Giggelberger-.

La *sociedad anónima* es el más reciente de los tipos societarios tradicionales. Su origen aparece ligado a las asociaciones privadas que se aplicaban a empresas de interés público. Su existencia estaba dada por autorización conferida por el Estado, que otorgaba a los socios el privilegio de la limitación de la responsabilidad y la facultad de ceder la cuota social.

Resulta incuestionable que el surgimiento de la *sociedad anónima* está ligada a la colonización y a las expediciones a grandes distancias, y que entre las ventajas que ofreció la figura entonces -como ahora- se destacan la posibilidad de concentrar capitales, facilitar el fraccionamiento del capital y representarlo mediante títulos negociables.

Posteriormente, la colonización y las expediciones de ultramar promovieron el surgimiento de una nueva forma de agrupación, con amplia concentración de capitales, con la posibilidad cierta de recurrir a mecanismos para el fraccionamiento del capital y representarlo mediante títulos negociables, para su circulación en el mercado.

La doctrina ubica -entonces- el nacimiento de la sociedad anónima -el instrumento al que nos hemos referido- entre los comerciantes holandeses del siglo XVII -Garrigues- cuando un sector mercantil de Ámsterdam, junto a los grandes navegantes holandeses, permitieron abrir nuevas perspectivas al comercio y a la industria. Ese impulso creador dio lugar a nuevas formas de empresa, constituidas exclusivamente por aportaciones de dinero, sustituyendo la base personal propia de la empresa individual y de la compañía colectiva por la base estrictamente capitalista, propia de la sociedad anónima. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602 sobre la base de ocho sociedades de navegación es, tal vez, la primera compañía constituida con las características de una sociedad anónima moderna.

Los especialistas también destacan las experiencias del *Banco di San Giorgio* en Génova y el *Monte dei Paschi* en Siena, ya que en ambos casos se trató de una organización autónoma que desarrollaba en provecho propio negocios diversos. Otro tanto ocurre con las *maone*, en las que cierta doctrina observa un primer paso hacia las sociedades coloniales del siglo XVII y XVIII. Las *maone*, palabra árabe que significa *socorro* o *ayuda*, estaban constituidas por un grupo de ciudadanos que proveían, bajo directivas estatales, a los gastos necesarios para organizar una expedición naval, usualmente de ultramar, dirigida a la conquista de alguna colonia.

Pero lo que resultó -sin duda- el gran salto de estas instituciones al mundo jurídico fue el Código de Napoleón de 1807, que permitió la creación de *sociedades anónimas* sin necesidad de un acto legislativo específico para cada sociedad, pues -como lo ha señalado la doctrina- si bien el Estado se reservaba la facultad de ponderar la existencia de interés público mediante una decisión administrativa, finalmente las autorizaciones para funcionar eran generalmente otorgadas.

Ese esquema fue aplicado entre nosotros con la sanción del Código de Comercio en 1862 y su posterior reforma en 1890.

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CONSTITUTIVO

La naturaleza jurídica del *acto constitutivo* de la sociedad -no de la sociedad propiamente dicha, pues ésta es un sujeto de derecho, conforme lo disponen los arts. 148, inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 2 de la ley 19.550- es algo que ha dividido a la doctrina en razón de una cuestión sumamente compleja que se presenta en el caso, cual es que la constitución de la sociedad no sólo determina un *haz de relaciones jurídicas* en relación con los sujetos que la conforman, sino que da nacimiento -como lo hemos señalado- a un *nuevo sujeto de derecho*.

Dicho de otro modo, el acuerdo de voluntades -o la declaración unilateral de voluntad, en el caso de las sociedades anónimas unipersonales-:

- i) plasma un conjunto de derechos y obligaciones para las partes; y
- ii) da lugar a la creación de un nuevo sujeto de derecho, dotado del atributo de la personalidad jurídica, el cual es -a su vez- titular de nuevos derechos y obligaciones diferentes de aquellos que vinculan a los sujetos que lo crearon -o al sujeto del cual emana la declaración unilateral de voluntad en el caso de las sociedades unipersonales-.

De allí la diversidad de catalogación que la doctrina ha efectuado de este fenómeno tan complejo, al que le ha atribuido -según el intérprete- la naturaleza de:

- a) un acto colectivo;
- b) un acto complejo;
- c) una institución; y
- d) hasta de un contrato -con diferentes variantes en cada caso-.

2.1. La teoría del acto colectivo

Quien con mayor énfasis ha defendido la teoría de que la sociedad comercial es un acto complejo es Messineo, al sostener que la constitución de una sociedad comercial no es otra cosa que un acto jurídico celebrado con la participación de quienes desean ser socios, bastando con la expresión que ellos hagan de su consentimiento en forma mayoritaria. El acto se conforma mediante la expresión de las voluntades por parte de los participantes en él, en forma paralela, de un modo absolutamente contrario a lo que ocurre en los contratos, donde las expresiones de voluntad se entrecruzan.

Según esta posición, la expresión de voluntad colectiva, otorgada por cada uno de los convocados, convierte la voluntad del acto en una *voluntad única*, amalgamándose de tal manera de conformar el acto en *una sola voluntad*, producto de la *suma de voluntades expresadas*.

La mayoría de la doctrina ha rechazado la concepción otorgada al acto constitutivo de sociedad comercial como un acto colectivo.

2.2. La teoría del acto complejo

Otra parte de la doctrina ha entendido que la naturaleza jurídica del acto constitutivo es, en realidad, un *acto complejo*. Si bien Halperin entre nosotros ya había alertado en relación con la similitud existente entre las teorías del acto colectivo y del acto complejo y la circunstancia de que durante muchos años ambas denominaciones se habían atribuido indistintamente sin diferencias sustanciales, cabe también destacar que mientras en el acto complejo las voluntades de los declarantes se funden en una sola voluntad única perdiendo su individualidad, en el acto colectivo esa unión no alcanza a desdibujar su diferenciación y, discernibilidad en el interior del acto.

Adicionalmente, parte de la doctrina también ha puesto de relevancia la siguiente diferencia:

- i) el *acto complejo* -para algunos autores- es un *negocio unilateral de sustrato pluripersonal*, constituido por un conjunto de declaraciones de voluntad formuladas por varias personas que conforman una sola parte, y que obran todas en una misma dirección en protección de un único interés; mientras que

- ii) el *acto colectivo* está constituido por *una sola deliberación adoptada por una pluralidad de personas en una unidad de tiempo y de lugar, luego de exámenes y discusiones*.

La mayoría de la doctrina ha rechazado la concepción otorgada al acto constitutivo de sociedad comercial como un *acto complejo*.

2.3. La teoría de la institución

Conforme a esta visión, la sociedad comercial en realidad consistiría en un *ente o idea fuerza a la cual la comunidad le ha otorgado un valor al reconocerle instrumentalmente la capacidad de permitir el desenvolvimiento y desarrollo de actividades económicas que considera beneficiosas para el conjunto de la comunidad*.

Consecuentemente, el Estado o el poder administrador le reconoce a esta agrupación el carácter de sujeto de derecho o permite su nacimiento -como ente- para el cumplimiento de tales fines.

La denominación de *teoría de la institución* deviene -justamente- de este hecho de reconocimiento, pues el Estado -a través del legislador o de un acto particular según sea el caso- *instituye* la sociedad como medio instrumental para el cumplimiento de esos fines.

Entre nosotros, la posición institucionalista ha sido especialmente sostenida por Videla Escalada y criticada fuertemente por Halperin, aunque se ha considerado la posible aplicabilidad del criterio al tipo de la sociedad anónima, en virtud de la estructura predominantemente organizativa que tal tipo tiene.

La trascendencia que puede acarrear adoptar o aceptar la teoría de la institución se vincula con el hecho de que habilitaría una mayor intervención del Estado en las actividades económicas privadas, avanzando sobre el ámbito de libertad otorgada -por la misma ley- a los particulares.

2.4. Las tesis contractualistas

En forma contraria a la posición institucionalista se encuentran las *teorías contractualistas*, según las cuales -siguiendo la tradición en la materia- la sociedad constituye un contrato, tal como ha sido recogido este criterio en el Código Civil derogado, y receptado mayoritariamente en el ámbito del derecho mercantil, a partir de la vigencia del Código de Comercio, primero, y de la Ley de Sociedades 19.550 -que no admitía originariamente la sociedad unipersonal-, después. Claro está que dentro de las posiciones que sustentan la tesis contractual no hay absoluta coincidencia, pudiendo encontrarse:

- i) quienes identifican a la sociedad con los contratos clásicos;
- ii) quienes la incluyen dentro de los contratos plurilaterales; y
- iii) quienes la encuadran en los contratos plurilaterales de organización.

2.4.1. CONTRATO BILATERAL

Recuerda Vanasco que quienes sostienen que la sociedad es un *contrato bilateral* argumentan que las obligaciones de los socios en realidad no se enfrentan entre sí en forma grupal, sino que corresponden individualmente cada una de ellas a la contrapartida de una obligación de la sociedad que nace con el acuerdo de voluntades.

Dicho de otro modo, el *contrato bilateral se celebra por cada socio respecto de la sociedad, de un modo tal que el número de socios incide en la calificación, toda vez que el obligado es en realidad obligado frente al grupo representado por la figura societaria.*

Los fundamentos de la posición no convencen, en la medida en que si los contratos bilaterales son aquellos en los cuales las partes se obligan, recíprocamente, la una hacia la otra, siendo que del acuerdo de voluntades con numerosas partes nace un nuevo sujeto de derecho, no parece adecuado:

- i) pretender que los consocios de cada socio constituyan un grupo diferenciado en cada vínculo contractual; y
- ii) que se pueda admitir que hay una contraparte del socio conformada por la “sociedad” cuando el sujeto de derecho “sociedad” recién nace a partir de la celebración del contrato, resultando un producto de éste -tomando la expresión en sentido lato-, y no con anterioridad a dicho contrato como para conformar una contraparte del socio.

2.4.2. CONTRATO PLURILATERAL

Esta categoría de contratos, concebida por algunos autores alemanes, luego acercada hacia nosotros por Ascarelli, y consagrada en el Código italiano de 1942, trata como contratos plurilaterales a aquellos que tienen, originaria o potencialmente, *más de dos centros de intereses diferenciados, sin que exista reciprocidad o interdependencia entre todas las prestaciones nacidas del contrato.*

Los contratos plurilaterales suelen presentar una o más de las siguientes notas características:

- i) finalidad común;
- ii) organización administrativa patrimonial de cierta complejidad y duración; y
- iii) apertura al ingreso de terceros, sin que esto desnaturalice la figura.

Los *contratos plurilaterales* han sido también considerados como una *especie de los contratos de colaboración*, género que se opone a los *contratos de cambio*.

Muchas veces se ha sostenido que los contratos plurilaterales tienen por objeto el dar nacimiento a un nuevo sujeto de derecho. Esto no es así; si bien el contrato plurilateral de organización por excelencia es el *contrato de sociedad*, el grado de separación patrimonial dependerá de la regulación existente en cada caso, de modo que no todos los contratos plurilaterales llevan en su esencia la necesidad de generar el nacimiento del nuevo sujeto de derecho.

De acuerdo a cómo se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades el contrato de sociedad comercial, el mismo se adecua al concepto de contrato plurilateral cuando involucra a dos o más socios.

2.4.3. CONTRATO PLURILATERAL DE ORGANIZACIÓN

Una de las clasificaciones clásicas en materia de contratos es aquella que los diferencia en contratos:

- i) de *cambio* -y dentro de estos están los denominados contratos paritarios o discrecionales, los celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, y los contratos de consumo-;

- ii) *asociativos* -donde también hay contratos paritarios y discrecionales y otros celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas-; y
- iii) de *organización*.

Así:

- a) Son *contratos de cambio* aquellos que cuentan con prestaciones contrapuestas por las partes que los celebran; así, la prestación de una de las partes es la contraprestación y el interés de la otra, y viceversa.
- b) Los *contratos asociativos*, por el contrario, son aquellos en los cuales las prestaciones de las partes no tienen carácter contrapuesto, sino que se trata de obligaciones yuxtapuestas que tienden a un fin común para las partes. Por lo tanto, la causa de la prestación de cada una de las partes no se halla en las contraprestaciones de los demás, aunque no se pierdan de vista los intereses individuales, sino en la participación que cada contratante se propone obtener en la gestión de todas las prestaciones asociadas, existiendo un objeto o finalidad común que se persigue mediante la colaboración de todos los asociados que tratan de satisfacer, por esa vía, sus propios intereses individuales.
- c) Los *contratos de organización* son aquellos que tienen por finalidad organizar grupos o categorías, que mantengan una existencia más o menos duradera de la colectividad de los asociados que, en muchas ocasiones, llega a sobrepasar la duración de la vida individual de éstos. Generalmente, los contratos de organización revisten el carácter, también, de contratos plurilaterales.

Bajo el régimen de la ley 19.550 no caben dudas de que el contrato de sociedad:

- i) cuando la sociedad se conforma por dos o más sujetos, el acto constitutivo debe considerarse como un contrato plurilateral de organización -sobre la base de haber adoptado la tesis de Ascarelli-; y
- ii) cuando la sociedad se conforma por un solo sujeto -sociedad unipersonal- el acto constitutivo debe considerarse una *declaración unilateral de voluntad* -regida por el art. 1800 del Código Civil y Comercial de la Nación-.

2.4.4. NUESTRA OPINIÓN

Si bien debemos reconocer que el contrato de sociedad bajo el régimen instituido por la ley 19.550 -cuando la sociedad está constituida por dos o más socios- debe ser considerado un *contrato plurilateral de organización*, la circunstancia de que el acto constitutivo hace nacer un nuevo sujeto de derecho y la evolución que el régimen societario, conforman cuestiones novedosas que se han presentado en el mundo contemporáneo -tendiendo hacia una concepción con mayores ingredientes negociales e institucionales- lo que necesariamente provoca la pertinencia de tener que proceder a una revisión de dicho concepto en la reforma legislativa introducida a la ley 19.550 por la ley 26.994.

En efecto; como consecuencia de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y de la ley 26.994, ha existido un replanteo del instituto societario -en lo que hace a su naturaleza constitutiva- en razón de:

- i) el reconocimiento de las sociedades comerciales como *estructura a través de la cual se pueden organizar derechos patrimoniales*;